

1500300-68.2022.8.26.0210

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... é equiparado aos hediondos.

O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais.

Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.

Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1500300-68.2022.8.26.0210 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500300-68.2022.8.26.0210

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ CLAUDIO SILVA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. LUIZ CLÁUDIO SILVA DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 13, foi denunciado e viu-se

processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 3 de abril de 2022, por volta das 11h, na Avenida 35 nº 149, Bairro Jardim Eldorado, nesta cidade e Comarca, teria trazido consigo, com finalidade de traficância e entrega ao consumo de terceiros, vinte e quatro porções de cocaína, com peso aproximado de 22,17 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

É da denúncia que “na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando avistaram o denunciado caminhando pela via pública com uma mochila nas costas. Ele, ao perceber a aproximação policial, abandonou a mochila e entrou em um armazém.

Os policiais conseguiram abordá-lo e, submetido à busca pessoal, apreenderam em um bolso de sua bermuda 24 (vinte e quatro) pinos de cocaína e no outro a quantia de R\$ 158,00 (cem e cinquenta e oito reais) em dinheiro, cf. auto de exibição e apreensão de fls. 9/10. Indagado, o denunciado admitiu aos policiais que estava traficando drogas para terceiro.

Ainda, os policiais conseguiram apreender a mochila que o denunciado carregava e, no seu interior, apreenderam uma arma de fogo de fabricação caseira, porém, inapta para disparo (cf. laudo de fls. 100/102).”.

A denúncia de fls. 109/110 foi recebida em 20 de abril de 2022 (fls. 112/113), sendo o Réu citado (fls. 134), apresentando defesa preliminar em fls. 123/126, rejeitada em fls. 135/137. Durante a instrução foi colhida prova oral e interrogado o Réu (fls. 172/174).

Em memoriais o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (fls. 172/173).

A douta Defesa, por seu turno, requereu a improcedência da ação, alegando a inexistência de provas que indicassem ser o Réu narcotraficante, uma vez que o depoimento dos policiais teria incluído palavras à versão do Acusado, daí por que deveria ser absolvido. Subsidiariamente pediu a concessão de medida cautelar diversa da prisão porque tem um filho recém-nascido (fls. 175/179).

É o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está estampada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/07), auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, auto de constatação de fls. 27/30, comprovante de depósito de fls. 163, pelo laudo de exame químico-toxicológico a fls. 169/171, além da prova oral colhida durante a persecução penal.

A autoria é certa contra o Réu que em Juízo negou o teor da denúncia, aduzindo que estava na Rua 4 quando virou a esquina fumando um baseado e ao avistar a viatura dispensou o cigarro e entrou no varejão. Disse que não trazia qualquer coisa consigo, desconhecendo de quem seria a droga, que sequer teria sido encontrada. Ademais, não seria conhecido dos policiais porque estava somente há sete dias residindo em Guaíra, trabalhando como autônomo. Disse, ainda, que faz uso de maconha e cocaína, não conhece os policiais e que a cena teria sido vista pelo dono da mercearia e a filha.

Sua versão não se sustenta, sendo que, verdadeira, teria feito segura prova a respeito, em especial fazendo ouvir as testemunhas que seriam presenciais, ou seja, o dono da mercearia e sua filha, ônus que lhe competia, com base no artigo 156 do Código de Processo Penal.

O policial militar Carlos afirmou que estavam em deslocamento para atender outra ocorrência quando avistaram o Réu com uma mochila e ele, ao ver a viatura, tentou fugir, dispensou a mochila e entrou na quitanda. Foi abordado e com ele localizaram a droga e o dinheiro, em bolsos separados, instante em que o Acusado confessou que a droga era destinada ao tráfico, trabalhando para Wellington. Contou o militar, ainda, que a mochila tinha uma arma, o Réu não aparentava estar sob efeito de drogas e não o conhecia. No mesmo sentido o depoimento de Tarcísio, que ainda esclareceu que o Acusado detalhou que a cada quinze porções de droga vendida ele ganhava R\$ 30,00 e que apesar de não o conhecer naquele mesmo dia receberam a informação de que uma pessoa, com as características do Réu, estava traficando no local, conhecido ponto de venda de drogas.

A conduta do Acusado, pois, indica que no dia, horário e local apontados na denúncia, trazia substância entorpecente para fins de traficância. A isso se chega com a prova coligida aos autos, notadamente a quantidade de droga apreendida, o local já conhecido dos meios policiais por ser ponto de tráfico, o fato de ter tentando o Réu correr ao avistar a viatura, dispensando uma mochila que continha uma arma, ainda que inapta ao uso, bem como por ele ter declarado, no momento em que foi preso, que traficava, dando detalhes de sua atuação no comércio clandestino. No mais, o Réu já demonstrou possuir envolvimento com o narcotráfico, tanto que anteriormente condenado por esta prática (cf. fls. 34/35) e nem mesmo aparentava estar sob o efeito de droga no momento da abordagem. Tais condutas apontam que o Réu utilizava o entorpecente apreendido consigo para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343, de 23.08.2006.

Lado outro, o simples fato de ser usuário - sequer comprovado -, não exclui a possibilidade da narcotraficância, sendo, no mais, condutas que comumente caminham juntas.

Dessa forma, considerando o quadro posto, descabe se falar em insuficiência probatória. Oportuno salientar que "Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado" (TJSP, Ap. 990.09172372-0, 5ª C.D.Crim., Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 03.12.2009).

Nem se olvide pelo fato de a acusação se embasar somente no depoimento prestado por policiais, que é válido e está em consonância com as demais provas, sem existência de qualquer indicativo de sua imprestabilidade, motivo que não podem ser descartados, notadamente porque o Réu não ofertou qualquer resistência válida ao depoimento deles e a alegação de terem criado versão para prejudicar o Réu não encontra eco nos autos.

A condição funcional não os torna suspeitos, valendo, outrossim, o princípio de presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados. Nesse diapasão, "Com relação aos depoimentos de policiais, os entendimentos jurisprudenciais têm convergido na direção de que são eles válidos e aptos ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha e as suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração da falácia, recaindo o ônus da produção destas na esfera da defesa, situação que inocorreu nos autos.

Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento dos mesmos quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram" (TJSP, Ap. 990.08.168537-0, 10ª

C.D.Crim., Rel. Des. Otávio Henrique, j. 16.04.2009).

Assim, tem-se o depoimento isolado do Réu dado em Juízo que, por motivos óbvios, possui intenção de se isentar das penas da narcotraficância e, de outro lado, o depoimento uníssono dos policiais militares, agentes públicos que contaram com detalhes a prisão do Réu, nada sendo levantado e muito menos comprovado contra eles, de forma que viesse a colocar em xeque seus depoimentos.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade. Sendo assim, reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

O Acusado é reincidente, demonstrando ter personalidade persistente na prática de condutas antissociais. Contudo, na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base no mínimo legal para não provocar um bis in idem com a agravante da reincidência. Sendo assim, apreciando os parâmetros legais ditados pelo artigo 59 do Código Penal, onde não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar, a pena-base ser fixada no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor à míngua de comprovação de suas condições financeiras.

Na segunda fase da dosimetria da pena, aumento-a em 1/3 (um terço) em razão de sua reincidência (cf. fls. 34, processo nº 0000041-41.2016.8.26.0572; fls. 34/35, autos nº 0002004-50.2017.8.26.0572 – específica), evidenciando persistência na prática de condutas antissociais, em especial deste crime equiparado ao hediondo, exigindo que sua reiteração seja objeto de maior repreensão, atingindo, então, o patamar de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, que a torno definitiva.

Sendo reincidente, inclusive específico, o Acusado não faz jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, mormente porque a forma como se desenhou os fatos vem a demonstrar que se dedica, indubitavelmente, à atividade criminosa do tráfico de drogas.

Nesse diapasão: “Para redução da pena, essencial que o réu seja 'primário', apresente 'bons antecedentes', comprove que 'não se dedique às atividades criminosas', assim como, 'nem integre organização criminosa'. Evidente que essa causa de redução da pena está reservada àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de drogas. E mais, os parâmetros para a graduação da redução (1/6 a 2/3) devem ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que envolvam o caso concreto, podendo variar dentro do seu campo de incidência. Essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder. Ao julgador compete a análise do impulso, do fator determinante da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir tratar-se mesmo de caso de um criminoso meramente ocasional, ou mesmo, se vem tomando aquela conduta como estilo de vida, para que possa, não apenas determinar a gradação da redução da pena, como até mesmo o total afastamento da causa de redução” (TJSP, Ap. 0003548-97.2014.8.26.0210, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Luiz Antonio Cardoso, j. 30.07.2019).

O regime de cumprimento de pena adequado, por se tratar de crime equiparado ao hediondo, é o inicial fechado. Nesse panorama: “O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto acerto, não só por previsão legal artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 como, também, pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e social. Tanto é que o delito é equiparado aos hediondos.

O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais.

Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.

Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas, considerado o § 4º, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem dúvida, crime grave.

Mas há os considerados hediondos.

Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo, absolutamente intolerável.

Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo, como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?

O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a cocaína e o 'crack', por exemplo, além de causarem dependência, destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e o que é pior: com mínimas chances de recuperação. Bem por isso que se trata de crime hediondo.

A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.

O legislador, com a edição da Lei nº 11.343/06, passou a punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados.

Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.

Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que menos os preocupa" (TJSP, Ap. 0000555-39.2016.8.26.0557, 15ª C.D.Crim., Rel. Des. Poças Leitão, j. 01.02.2018).

Por outro lado, é vedada a concessão de sursis ou substituição por pena restritiva de direitos, pela ausência do requisito subjetivo. Ressalto, quanto tal aspecto que, não obstante a decisão tomada no HC 97.256/RS, do STF, que não possui cunho vinculante, com a devida vênia, não se verifica compatibilidade lógica da pena restritiva com a natureza da infração, sendo que deveria a defesa fazer prova de que o Acusado possui condições da substituição da pena corporal, o que não é afastado nem mesmo diante da Resolução nº 5/2012 do Senado, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, porquanto esta deve se dar respeitando parâmetros preestabelecidos pela lei, notadamente porque o artigo 5º, inciso XLIII, da CF/88 determinou regime mais rigoroso na reprimenda de crimes hediondos e equiparados.

Relevo, ainda, que a disposição do artigo 44 do Código Penal, que trata da conversão de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não é de aplicação automática, pois elenca os requisitos legais para tanto. Ali, em seu inciso III, estabelece que somente é aplicável a comutação quando a conduta social do réu, além dos motivos e circunstâncias do delito, forem favoráveis. A simples prática do narcotráfico, este o flagelo de nossa sociedade, indica o sujeito ativo do crime como pessoa portadora de péssima conduta social, sendo que os motivos e circunstâncias do crime são, evidentemente, desfavoráveis. Para isso, basta se ter contato com um usuário de entorpecente para se verificar a miséria que se tornou sua existência (e de sua família), tão-somente pelo consumo daquilo que é oferecido pelo traficante (ainda que seja um "pequeno" traficante).

Para o crime de narcotráfico, circunstâncias como primariedade, bons antecedentes

ou emprego lícito (das quais o Réu não é possuidor de nenhuma) servem para fixar a pena aplicada, bem como, quando o caso, o critério redutor. Contudo, não viabiliza a conversão em pena restritiva ou mesmo a fixação em regime que não o fechado, em vista dos diplomas legais acima citados, pois insuficiente à repressão e prevenção desta infração equiparada à crime delito hediondo. Nesse sentido, lapidar excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, verbis: "Ressalta-se que a decisão apresentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES, em 27 de junho de 2012, reconhecendo e declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 tem seus efeitos 'restritos ao processo e às partes litigantes', não possuindo efeito 'erga omnes', até porque, não afastada pela Suprema Corte a natureza hedionda do delito de tráfico, justificando a imposição do regime mais gravoso, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando a imposição de regime fechado para o crime de tráfico de entorpecente: HABEAS CORPUS nº 189.960/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.08.2012; HABEAS CORPUS 216.265/SP. Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02.06.2012; HABEAS CORPUS 199.619/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.08.2012; e HABEAS CORPUS nº 225.568/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe. 27.08.2012.

Não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, havendo a necessidade de pronunciar algumas considerações. Com efeito, o Senado, na forma do artigo 52, inciso X da Constituição Federal e com olhos voltados para o julgamento do HC nº 97.256/RS, pelo Supremo Tribunal Federal, editou a Resolução nº 05/2012, cujo teor é a suspensão da parte que obstaculizava a conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa, inserida no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, com a devida vênia, o traficante, seja de pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que não encarcerado.

Em vista o postulado implícito da proporcionalidade (HUMBERTO ÁVILA, Teoria dos Princípios, Ed. Malheiros), que é uma espécie de norma jurídica derivada do devido, justo e adequado processo legal (FAIR TRAIL), não se mostra razoável que o traficante, condenado por delito equiparado a hediondo (artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal) venha a receber tratamento similar ao agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo.

Nesse contexto, pondera-se: de onde viria o numerário para o traficante cumprir a prestação pecuniária? E mais: onde o traficante, disseminador de vício, cumpriria prestação de serviços à comunidade ou entidade pública? Nas escolas? Nas creches? Nos orfanatos? Nos abrigos? Nos hospitais?

Em suma, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em casos de tráfico de entorpecente, uma vez que tal medida atenta contra a efetividade do processo penal na aplicação do justo concreto, atingindo frontalmente o caráter retributivo da reprimenda e a dimensão material ou substancial do 'DUE PROCESS OF LAW'.

Além disso, é válido ressaltar que os recentes arrestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça indicam que não há ilegalidade na negativa de permuta, quando fundada na multiplicidade e na natureza lesiva das drogas apreendidas, isso porque a conversão da sanção reclusiva não seria suficiente para a prevenção e a repressão do delito denunciado (HC 204115 / MG - Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA - DJe 15/02/2012). E, na espécie, como foram apreendidas porções consideráveis de 'maconha', a aplicação de pena alternativa encontra óbice na exegese do artigo 44, inciso III, do Código Penal, sendo insuficiente como resposta à culpabilidade do agente, aos motivos e às consequências do exercício da atividade ilícita" (TJSP, Ap. 0005407-56.2011.8.26.0210, 4ª C.D.Crim., Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 18.12.2012).

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do CPP, com redação dada pela Lei 11.719, de 20.06.2008, porquanto o crime apurado é classificado como vago, assim

entendido aquele que tem por sujeito passivo a sociedade, destacando, outrossim, que não se comprovou qualquer dano causado em sujeitos passivos secundários (pessoa submetida aos riscos da lesão).

À derradeira, tendo em vista que o Acusado foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo com ele localizada quantia em dinheiro sem comprovação de regularidade em seu recebimento, evidenciando-se ser o numerário fruto da venda de drogas ilícitas, com fulcro no artigo 63, caput, do aludido diploma legal, decreto a perda da quantia apreendida com o Réu, depositada em Juízo a fls. 163, que deverá ser encaminhada em favor da União, com o trânsito em julgado desta sentença (artigo 63, parágrafo 1º).

III. Isto posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, em consequência CONDENO o Réu LUIZ CLÁUDIO SILVA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa, em seu piso legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado, vedada a concessão de sursis e a substituição por pena restritiva de direitos. No mais, decreto a perda do valor apreendido com ele, depositado em fls. 163, em favor da União.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), bem como encaminhe-se o numerário apreendido, depositado a fls. 168, em benefício da União.

Diante da pena aplicada, em regime inicial fechado em razão da equiparação à hediondez do crime, o Réu, descontente com a decisão, deverá aguardar o julgamento do recurso preso, motivo por que mantenho sua prisão cautelar sem prejuízo da apelação, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ficando indeferido o pedido por substituição por medidas cautelares diversas porque não há inovação nos termos das decisões de fls. 70/73 e 135/137, que já analisaram e afastaram essa pretensão.

São devidas custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Guaíra, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA